

61회 변리사 2차시험(특허법)

0. 총평

* 난이도: 중상

방대한 사실관계 및 기술내용, 낯선 유형의 문제방식, 다소 애매모호한 설문 등을 비롯하여 특허법이 첫 번째 과목인 점까지 고려해 보면, 실제 시험장에서 수험생 분들이 매우 당혹스러웠을 것으로 예상됩니다. 몇 개의 쟁점을 제외하고는 기본서나 GS를 통해서 다룬 것이기는 하나, 이질적인 문제 스타일이나 사실관계의 분량 등을 고려할 때, 문제의 내용을 알고 있을 것을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 수험생 분들이 느꼈을 체감 난이도는 아주 높았을 것으로 보입니다. 실제 시험장에서는 객관적인 '특허법 실력'보다도 평정심을 유지하면서 헤쳐 나갈 수 있었는지, 즉 '멘탈적인 부분'이 중요하였을 것입니다.

역대급으로 어려웠을 시험을 이겨내고 오신 점에 격려의 박수를 드립니다. 아마 대다수의 수험생 분들이 스스로 생각하기에 원하는 만큼 완성도 있는 답안을 쓰고 오지 못했다고 걱정하실 것입니다. 다만, 이 시험이 상대평가라는 점을 다시금 되새기시면서 너무 낙담하지 않으시길 바랍니다. 이미 답안지는 우리 손을 떠났으며 현장에서 최선을 다해 답안을 써내고 온 만큼 일부러라도 긍정적인 생각을 하시길 당부드립니다.

다시금 시험을 치르고 오신 수험생 분들의 노고와 열정에 존중을 표합니다.

아래와 같이 문제별 간단한 해설을 남깁니다.

1. 문제 1

* 난이도: 중상

- 문제 스타일이 낯설고, 판례를 기반으로 하지 않은 사실관계가 복잡하게 구성되어 실제 현장에서 상당히 곤혹스러웠을 것으로 예상됨 ☞ 사실관계를 파악하고 목차를 현출함에 있어서 상당한 시간이 소요되었을 것으로 보임
- 판례 외에 특허법상 제도나 이론에 대한 기본기가 요구되는 유형임

설문(1)은 **절차보정 명령**에 대한 검토를 묻는 사례 유형임

- '특허청'의 '보정요구서'라는 표현에 대해 실무적 경험이 있다면 곧바로 절차보정 명령 사안이라는 점(즉, 방식심사상의 문제)이 직관적으로 파악되나, 수험생 입장에서는 곧바로 파악되기 어려울 수 있음 ☞ 방식심사상 특허출원에 수반된 i) 우선권주장의 절차적 요건과 ii) 대리권 흠결 여부에 대해 검토되어야 함
- 방식심사의 대상으로서 국내우선권 주장의 절차적 요건에 대한 정리(기본기)가 잘 되어 있어야 적절히 대응하였을 것으로 예상됨 ☞ 특허를 받을 수 있는 권리의 특정승계인(判例) 및 우선권증명서류 제출 요부(법조문)가 검토되어야 함
- 대리인 제도가 최근 판례를 통해서 쟁점화되었기에 예년보다는 상대적으로 더 대비되었을 것이나, 해당 판례 사안대로 문제화된 것이 아니기에 해당 문제를 수월하게 대응하기는 매우 어려웠을 것으로 예상됨 ☞ 포괄위임장으로 대리권 서면 증명이 이루어질 수 있는지(判例) 및 우선권주장/복대리에 대한 특별수권 요부(법조문)가 검토되어야 함

설문(2)는 국내우선권주장 제도 관련 단문 유형임

- 국내우선권 주장제도의 취지를 서술한 이후에 위 취지에 비추 효과를 중심으로 한 장점이 서술되어야 함 ㉠ 제도의 취지는 판례를 통해서 연습된 것이나, 그 장점은 일반적으로 준비되는 단문은 아닌 만큼 제도에 대한 이해를 바탕으로 답안을 서술하는 기본기가 요구됨
- 개량발명의 예시를 묻는 출제자의 정확한 의도가 직관적으로 파악되지 않는기에 현장에서는 특히 당혹스러웠을 것으로 예상됨 ㉡ 개량의 방식이나 종류와 같은 개념적인 설명이 요구되는 것인지 아니면 구체적인 개량 예시에 대한 서술이 요구되는지가 다소 불명확함

설문(3)은 보상금청구권 관련 사례 유형임

- 메인 쟁점인 보상금청구권이 직접 제시되지는 않았으나, 특허권 설정등록 이전의 타인의 실시와 관련된 권리로서 보상금청구권을 파악함에 어려움이 없었을 것으로 생각됨 ㉢ 해당 권리의 '성립 요건'과 '행사에 필요한 절차' 관련 논점이 직접 제시되었음은 물론, 배경도 적절한 수준으로 주어져서 난이도는 높지 않다고 판단됨
- 보상금청구권의 '성립요건'과 관련하여 제시된 사실관계에서 출원공개 시점, 업으로서의 실시 여부가 포섭되어야 함 ㉣ 나아가, 戊가 乙의 실제 특허출원 전(우선일 이후)부터 실시하고 있던 만큼 서면경고 요부 및 선사용권이 발생할 예비적 지위 여부가 검토될 필요가 있음
- 보상금청구권의 '행사에 필요한 절차'와 관련해서는 앞서 출원공개 시점이 검토되었기에 i) 등록이 필요하다는 점과 함께 ii) 등록을 위해 필요한 조치로서 심사청구 및 우선심사 신청이 서술되면 충분할 것으로 보임

설문(4)는 보상금청구권의 행사 관련 사례 유형임

- 소설문 1)은 보상금청구권이 특허권 설정등록 이후에 행사할 수 있다는 점은 물론, 준용규정에 따라 소멸시효가 검토되어야 함
- 소설문 2)는 구법상 '통상 받을 수 있는 금액'이라는 표현에서 '합리적으로 받을 수 있는 금액'으로 개정된 취지를 고려하여, 발명 A에 대해 丙이 지급하는 로열티(월 2,000,000원)와 같거나 또는 그 이상의 합리적인 실시 대가를 예상 금액으로 결론을 내릴 수 있을 것임 (* 한편, 보상금청구권이 특허법 제128조를 준용하고 있지는 않으나, 동조 제5항 관련 구법상 판례를 유추적용하여 제3자의 실시료를 참작할 수 있다는 논리를 구성할 수도 있음)
- 소설문 3)은 우선권주장을 통해 등록된 특허권의 존속기간 만료시점이 '우선일'이 아닌 '특허출원일'을 기준으로 기산한다는 점을 주의하여야 함

2. 문제 2

* 난이도: 상

- 최근 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결을 기반으로 하여 출제된 것으로 예상되나, 설문을 통해서 묻는바가 위 판례에서 직접 쟁점화된 부분이 아닌 사항도 포함하고 있기에 많은 수험생들에게 큰 당혹감을 주었을 것으로 예상됨 ☞ 소위 말하는 짝돌 설문 외에 득점을 가져와야 하는 설문들의 기제가 상대적으로 중요할 것임
- 더불어, 20점짜리 문제가 많은 설문과 소설문으로 배점으로 나누어져 있어서, 오히려 설문 별로 부여된 상대적으로 작은 배점을 맞추기가 오히려 어려웠을 것으로 생각됨

설문(1)은 권리범위확인심판의 확인대상발명 특정 및 확인의 이익에 대한 단문 유형임

- 주어진 배점이 적기 때문에 각각의 소설문 별로 일반론 서술이면 충분할 것으로 보임
- ‘청구취지의 특정’ ‘청구원인의 특정’에 대해서는 강의를 통해 반복 정리된 법리이기에 어렵지 않게 서술하였을 것으로 생각됨
- ‘확인 이익’ 측면에서는 주어진 사실관계나 심판의 대상으로서 확인대상발명의 특정과 함께 설문을 구성한 측면을 고려하면, 확인대상발명과 실제 실시발명과의 사실적 관점에서 동일성 요건에 관한 서술이 요구될 것으로 보임

설문(2)는 심결취소소송의 심리 및 판결 관련 법리검토 유형임

- 대법원 판례를 통해 직접 쟁점화된 법리가 아니어서 미리 대비하기 어려웠음은 물론, 매우 작은 배점에서 “판결의 이유, 효과 및 문제점”이라는 요소를 직접 주어서 이러한 부분을 채워야 한다는 부담감에 수험생들의 체감 난이도가 가장 높았을 설문으로 예상됨 ☞ 실제 시험장에서 높은 퀄리티의 답안작성은 현실적으로 매우 어려웠을 것으로 생각하고, 혹여 해당 설문에 대해 제대로 서술되지 못하였더라도 득점상 큰 역할을 하지는 않을 것으로 예상됨
- ‘청구인용판결’과 관련해서는, **i)(판결의 이유)** 확인대상발명의 특정요건 흠결을 이유로 각하여야 함, **ii)(효과)** 판결이 확정되면 각하심결이 취소되고, 확인대상발명이 특정되지 않았다는 점에서 심판관을 기속함, **iii)(문제점)** 심판비용을 원고가 부담하는 문제/여차피 각하되어야 할 심결을 취소하는 것은 소송경제에 반하는 문제가 지적될 수 있음
- ‘청구기각판결’과 관련해서는, **i)(판결의 이유)** 확인대상발명의 특정요건 흠결을 이 사건 심판청구는 부적법하고, 이 사건 심결은 결론에 있어서 정당함, **ii)(효과)** 판결이 확정되면 각하심결이 확정됨, **iii)(문제점)** 심판청구인이 심판단계에서 확인대상발명의 특정 흠결에 대해 보정의 기회를 보장받지 못해 절차적 방어권 흠결 문제가 지적될 수 있음

설문(3)은 심결취소소송의 심리범위 관련 법리검토 유형임

- 주어진 배점을 고려하면 특허법 제186조 제6항에 따른 심결전치주의와 심리범위 관련 판례의 서술 및 사안에 대한 결론으로 충분하였을 것으로 생각됨 (다만, “본안심리”라는 표현이 권리범위확인심판의 본안으로서 ‘확인대상발명이 특허 보호범위에 속하는지 여부’인지 아니면 심결취소소송의 본안으로서 ‘심결의 위법성 일반’인지 다소 모호한 면이 있음)

설문(4)는 특허권자 보호 관련하여 설명하는 사례 유형임

- 乙이 앞선 심판사건에서 구체적 증거를 제시하지 않은 상황인 점을 고려하면, 침해소송에서 甲은 증거의 구조적 편제를 보완하기 위한 규정으로서 구체적 행위태양 제시의무(제126조의2)

및 자료제출명령 제도(제132조)를 활용할 수 있음

- 권리범위확인심판 사건에서 패소하였으나, 사실관계상 “각하심결”이 확정된 것으로 예상됨
☞ 형식상 유려한 증거자료 확보를 위해 적극적 권리범위 확인심판을 다시 청구하는 방안을 강구할 수 있으나, 주어진 사실관계나 배점상 이는 중요 쟁점은 아닐 것으로 생각됨

3. 문제 3

* 난이도: 중

- 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결을 기반으로 하여 출제된 것으로 예상되며, 정정제도와 진보성 판단과 관련하여 전형적인 쟁점으로 구성됨
- ‘정정제도’ 및 ‘정정요건’과 관련된 법리는 교재와 강의를 통해 반복 연습했던 사항으로서 어렵지 않게 풀이하였을 것으로 예상됨 ☞ 특히 ‘정정요건’과 관련해서는 의외로 한번도 기출되지는 않았으나, 출제 가능성이 높은 쟁점으로 평가되었던 만큼 대비되어 있어야 했던 쟁점임
- ‘진보성’ 판단과 관련해서도 위와 마찬가지로 반복 연습되었던 유형임 ☞ 다만, 예년과 달리 구체적인 기술내용을 포함하고 있어, 유형 자체의 대비와는 별개로 실제 시험장에서는 시간의 압박과 사안 포섭에 대한 부담감이 상당했을 것으로 예상됨

설문(1)은 특허의 정정 및 정정요건에 대한 단문 유형임

- 특허무효심판에서의 정정을 할 수 있게 한 취지는 이미 여러번 기출된 사항임 ☞ 피청구인인 특허권자가 ‘별도로 정정심판을 청구하지 않더라도’ 청구인의 특허무효주장에 대해 ‘방어적 기회’를 마련해 줌으로써 형평을 도모하는 취지를 설명하면 충분함
- ‘정정의 허용범위’는 정정이 인정되기 위한 본안요건으로서 “정정대상(감정명 中 어느 하나)/정정범위(신규사항추가금지)/청구범위 정정제한(실확변 금지)/독립특허요건”에 대한 일반론이 서술되면 충분함

설문(2)은 오류의 정정(분명하지 않은 기재의 명확화)에 대한 단문 유형임

- 상술한 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결을 기반으로 서술되면 충분함 ☞ i) 기재 자체의 불명확 해소, ii) 기재 상호간 모순 해소 등을 포함한다고 해석함
- 그 외에도 배점상 i) 신규사항추가금지의 범위(특허발명의 명세서 또는 도면 범위) 및 ii) 독립특허요건의 미적용을 더 기재할 수 있음

설문(3)은 발명의 설명에 관한 정정 관련 판례를 기반으로 하는 법리검토 유형임

- ‘청구범위’는 발명의 설명 기재 중 전부 또는 일부를 보호범위로 특정하는 역할을 함/ ‘발명의 설명’은 공중에게 기술을 공개하고 권리를 해설하는 문헌으로서 역할을 함 ☞ 특허법은 청구범위 기재가 발명의 설명에 의해 뒷받침될 것을 규정함(즉, 청구범위와 발명의 설명 기재 사이에 모순이 없도록 요건화함)
- 위와 같은 취지를 설명한 이후에 판례를 기반으로 하여, ‘청구범위에는 기재되어 있지 않고 발명의 설명에만 기재된 사항’이 있더라도 이는 기재 상호간 모순이 아님을 근거로, 이 사건 정정은 분명하지 않은 기재의 명확화에 해당하지 않는 것으로서 부적법하다는 결론을 내릴 수 있음

설문(4)는 **진보성 판단** 관련 (준)실무형 문제임

- 기술적 내용에 대해 파악이 필요했기에 당혹스러울 수 있으나, 진보성과 관련된 문제(특히 용이성 판단 관련)는 충분히 강조되고 반복 연습된 유형이라 생각됨
- 제시된 사실관계에 있어서, “① 공통점 이외에 제시된 차이점 파악 → ② 위와 같은 차이에 대한 암시나 시사 없음 + 선행기술과 해결하고자 하는 기술적 과제가 상이함 & 위와 같은 차이를 극복하는 것은 기술적 의의를 상실케 함 + 예측하기 힘든 특유의 효과 → ③ 동기유발 無 & 통상의 창작 범위라고 볼 수 없음 + 이러한 차이는 사후적 고찰이 아니므로는 도출되기 어려움”과 같은 파악 및 법리적인 판단이 요구됨
- 진보성 판단에 관한 법리(용이성 판단), 특히 사후적 고찰 금지 관련 법리를 서술한 이후에 위와 같은 논리에 근거하여 법리적인 사안 포섭 및 결론을 도출하면 충분할 것임 (※ 기술적 내용에 대한 구체적인 포섭도 중요하겠지만, 그보다 이를 근거로 진보성 판단 법리를 적용해 나가는 과정을 보여주는 것이 더욱 중요할 것으로 생각됨)

4. 문제 4

* 난이도: 중

- 설문(1),(2)만 보자면 전통쟁점&최신중요쟁점에 대한 단문 문제에 속하는 것으로서, 매우 중요하게 강조되고 반복 연습된 유형임 ☞ 단, 사실관계가 주어진 형식의 단문 문제 특성상 주어진 사실관계와 관계된 법리의 서술이 요구됨
- 설문(3)은 대비하지 못할 만한 쟁점은 아니나, 매우 작은 배점임에도 기술적 내용을 포함한 상당한 양의 사실관계를 파악하고 답안지에 사안 포섭을 하여야 하는 비효율(?)이 있음 ☞ 설문 (1),(2)를 독립적으로 보자면 대처하기 수월한 쟁점임에도, 실제 시험장에서는 주어진 문제 스타일의 당혹스러움과 4번문제를 풀이하는 시점이라는 특수성까지 고려하면, 더욱 평정심을 유지하기 어려웠을 것으로 예상됨

설문(1)은 **확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지 판단**과 관련된 단문 유형임

- 구성요소 완비의 원칙(문언침해), 균등론(균등침해)을 중심으로 서술하면 충분함 ☞ 배점상 전제법리로서 특허발명의 보호범위 해석(제97조, 청구범위 기준)/확인대상발명의 파악(설명서 기준)을 간단히 먼저 적어줄 수 있음
- 그 외에도 이용/선택/생략의 법리 등도 더 서술하는 것도 고려할 수는 있을 것이나, 주어진 사실관계까지 고려해 보면 위와 같은 서술이 배점에 들어갈 확률은 낮다고 생각됨

설문(2)는 **균등 제1요건**에 대한 판례 기반의 단문 유형임

- 균등 제1요건 판단의 법리에서부터 주어진 사실관계상 공지기술과의 관계까지 판례를 중심으로 서술할 것이 요구됨

설문(3)은 설문(2)의 법리에 따라 **균등론을 사안에 적용**하는 (준)실무형 문제임

- 주어진 배점이 매우 낮음에도 기술적 내용 파악에 상당한 시간이 소비됨 ☞ 실제 시험장에서 적절히 대처하기 매우 곤란하였을 것이므로, 대다수의 수험생들이 스스로 만족할 만한 답안을 써내기는 어려웠을 것으로 생각됨
- 주어진 사실관계에 있어서 “① 발명의 설명 등을 참작하여 특허발명의 특유한 해결수단이

기초하고 있는 기술사상의 핵심 파악(슬라이더의 전후방향 이동방식) → 공지기술과의 비교(회전당김식/회전누름식: 특허발명의 기술사상의 핵심을 회전식까지 넓게 파악할 수는 없음) → 확인대상발명이 특허발명의 기술적 사상의 핵심을 채택하고 있는지(소극, 버튼부재의 회전장착 방식) → 과제해결원리 동일 X: 균등침해 부정”과 같은 파악 및 법리적인 판단이 요구됨
- 배점이 매우 작은 만큼 기술적 내용에 대한 구체적인 포섭보다는, 법리적으로 올바른 적용과 주장을 하고 있음을 보여주는 것이 더욱 중요할 것으로 생각됨